



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

**תיקים: 5/437/2014**

**מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב - יפו**

**בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן**

**התובעים:**

1. בוסאני שלום
  2. בוסאני ברוריה
  3. זילבר יובל
  4. אלגרט יעל
  5. שמגה סטלה
  6. חסידי אייל
  7. חסידי חנה
  8. לוין אמיר
  9. ש.ב.ן חברה קבלנית לבניין ולהשקעות בע"מ
  10. יעיש ערן
  11. יעיש מיכל וקס
  12. רפאלי נדב
- ע"י ב"כ עוה"ד אדם שפרוך  
ממרכז עזריאלי 1 תל אביב

**נ ג ד**

**הנתבעים:**

1. יהודית קאופמן (קינן)
  2. אורן קינן
  3. אייל קינן
  4. עינת קינן
- ע"י ב"כ עוה"ד נוראל אור  
מדרך מנחם בגין 23 תל אביב

**פסק דין**

**מבוא**

1. תובענה זו עניינה בבקשת התובעים לאישור פרוייקט על פי תמ"א 38 בהתאם להוראות חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008 בבית ברחוב יואב 14 רמת גן הבנוי על חלקה 66 בגוש 6206.
2. במסגרת דיון לשמיעת ראיות שנערך ביום 23.03.15 הגיעו הצדדים להסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין חלקי במסגרתו הוסכם, בין היתר, כי הנתבעים יסירו את התנגדותם התכנונית לפרויקט וגם יחתמו על המסמכים הנדרשים לביצוע הפרויקט (להלן: "הסכם הפשרה" ו-"פסק הדין החלקי").
3. בנוסף קבעו הצדדים כי ימונה שמאי בהתאם להוראות סעיף 6א לחוק החיזוק אשר יתייחס בחוות דעתו לסוגיות מוסכמות כלהלן-



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

**תיקים: 5/437/2014**

**מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב - יפו**

"א. בחינת שווי דירת הנתבעים לפני ביצוע הפרויקט ושווי דירת הנתבעים לאחר ביצוע הפרויקט, בהתאם להסכם תמ"א הקיים והמצב התכנוני המאושר.  
ב. השמאי יעריך שווי מטר מובנה לדירת הנתבעים לאחר ביצוע הפרויקט.  
ג. השמאי יבחן ויעריך את הפרש התמורה לדירת הנתבעים, בין ההסכם הקיים לבין הצעת צאליח רוטשילד מיום 6.9.2012 (נספח 14 לתצהיר מר קינן) ובנוסף מכתב מעו"ד אור מיום 17.9.2013 (סעיף 6 לנספח 4 לתצהיר הגב' צאיג).  
ד. השמאי יעריך את שווי חלק הנתבעים בחלל הגג במצב הקיים בבית וכן שווי זכות השימוש לחניית אופנוע בחצר הבית עפ"י המצב הקיים".

4. עוד נקבע בהסכם הפשרה כי הצדדים מותירים להכרעתי את השאלה בדבר שיעור הפיצוי המגיע, אם מגיע, לנתבעים (סעיף 4 להסכם) וכי היזמית, התובעת 9, מתחייבת לשלם לנתבעים כל סכום שיפסק בפסק הדין, אם יפסק (סעיף 5 להסכם).

5. בהתאם לפרוצדורה הקבועה בחוק החיזוק ועל פי הסכמת הצדדים כאמור מונה השמאי טובי גרש כמומחה מטעמי וחוות דעתו הוגשה ביום 30.09.15.

בהתאם להחלטתי מיום 01.11.15 בתיק ב"ב 615/15 הוגשה ביום 02.11.15 השלמה לחוות הדעת לאור שאלות הבהרה מטעם הנתבעים.

6. בהתאם להסכם הפשרה ופסק הדין החלקי עלי להכריע בשאלת הפיצוי בשתי סוגיות כלהלן (סעיף 4 להסכם הפשרה):

האם מגיע פיצוי לנתבעים, ואם כן כמה, בגין הצעה חלופית לפרויקט (הכוללת אפשרות לפיצול דירות, גובה דירות מינימאלי יהיה גבוה לפחות ב- 5 ס"מ מהמוצע וכל דייר יהיה זכאי לחניה שניה בעלות בנייה בפועל) (סעיף 6 למכתב ב"כ הנתבעים בנספח 4 לתצהיר צאיג) (להלן: "פיצוי בגין הצעה חלופית");

האם מגיע לנתבעים פיצוי, ואם כן כמה, בגין דרישתם לקבלת דירה חדשה בשטח 141 מ"ר, רצונם לפצל דירתם ל- 3 דירות ופיצוי בגין חניית אופנוע שנעשה בה שימוש לאחר שנרכשה מבעלי הדירות (סעיף 8 למכתב הנ"ל) (להלן: "פיצוי בגין דרישת הנתבעים").

## **סיכומי הצדדים**

### **תמצית סיכומי התובעים**

7. הנתבעים אינם זכאים לפיצוי בגין ההצעה החלופית של צליח וזאת לאור קביעת השמאי כי מדובר בהפרש בן אחוזים בודדים, כשלא ברור כלל מהי ההצעה העדיפה, ודאי כאשר הצעת צליח כוללת חלופות שלא נבחנו. בעלי הדירות בחרו בהתקשרות עם שב"ן וההסכם עמה מחייב ולא ניתן ליתן למיעוט לערער על קביעה זו, ודאי כאשר מדובר בעסקה אלטרנטיבית ערטילאית. החיוב בפיצוי אינו מעוגן בכלל בסיס משפטי וחיוב בפיצוי ישמיט את הקרקע מתחת למטרות חוק חיזוק. הצעת צליח גם איננה עדיפה – שווי הדירה בהצעה



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

תיקים: 5/437/2014

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב - יפו

זו נמוך ב- 180,000 ₪ משווי דירה על פי הפרויקט עם שב"ן. הצעת צליח כוללת הנחות בלתי ישימות - כך, לגבי הקומה בה תמוקם דירת הנתבעים. כך, אין כל אסמכתא כי ניתן לפצל את דירת הנתבעים ובכל מקרה הדבר לא מופיע בהצעת צליח. כך, אין כל יסוד בהצעת צליח לטענת הנתבעים לזכאותם לכאורה לקבלת דירה בשטח 141 מ"ר שתפוצל ל- 3 דירות. כל התרחישים לתשואה נוספת לנתבעים עניינם בפיצול דירתם. דא עקא, לא הוכחה, בכל דרך, אפשרות לפיצול מבחינה הנדסית ותכנונית והדבר לא עלה כלל בהצעת צליח. משכך, הצעה זו, ממילא, איננה עדיפה.

*תמצית סיכומי הנתבעים*

8. יש לבחון באם הסכם התמ"א נגוע באי שוויון ובהתאם האם זכאים הנתבעים לפיצוי. ההרחבה על פי ההסכם מקנה 25 מ"ר לכל דירה ללא כל קשר לגודלה הנוכחי ומשך נוצרת אפליה שכן הנתבעים מקבלים הרחבה בשיעור של 26% בלבד. בהתאם התמורה לבעלי הדירות, להם חלק גדול יותר ברכוש המשותף, קטנה יותר. היזם הינו בעל דירה לאחר שרכש את זכויות בעלי דירה בבית אשר התנגדו לפרויקט. הרחבת הדירות המתוכננת מ- 18 ל- 25 מ"ר נעשתה בשל מעורבותו של מר אורן קינן ולפיכך גם הנתבעים, כמו היזם, זכאים לעמלה עבור המטרים הנוספים ש"השיגו" עבור בעלי הדירות. התובעים והיזם סרבו להצעת הנתבעים לשלם עבור חלקם בזכויות המגיעות להם כולל הרווח היזמי. היזם מכר דירות לחברי הנציגות בניגוד להוראות הסכם התמ"א. ניתן לפצל את דירת הנתבעים, גם על פי הצעת היזם במסגרת מו"מ לפשרה.

חוות דעת השמאי רשלנית ובלתי מקצועית – דירת הנתבעים הינה בגודל 3.5 חדרים ולא 2.5 כפי שנרשם ובכך שם את דירתם בחוסר של 800,000 ₪ לפחות; השמאי השמיט פרק שלם מהנחיות השומה אותן קיבל; השמאי התעקש שלא לשום את שווי חניית האופנוע; נעשו טעויות בעסקאות ההשוואה – עסקת רכישת דירה בבית על ידי היזם לא נלקחה בחשבון, הובאו עסקאות ספורות בלבד שאינן רלבנטיות ובהתאם שווי למ"ר מבונה שנקבע נמוך בעשרות אחוזים; השמאי התעלם מכך שחלל גג הרעפים (המופרד מדירת הנתבעים בתקרת רביץ בלבד) אינו חלק מן הרכוש המשותף. לנתבעים רשות בלתי הדירה לחניית אופנוע ברחבת הכניסה לאור הסכמה לפני עשרות שנים במסגרתה שיפצו הנתבעים את שביל הכניסה תמורת החניה האמורה ולחילופין בידי הנתבעים זכות זיקת הנאה לשטח האמור. הנתבעים זכאים לפיצוי בגין העובדה שהם נאלצים לוותר על זכויותיהם הקנייניות בזכויות הבניה והרכוש המשותף ששווין נאמד בסך של 8 מיליון ₪.

*תמצית סיכומי תשובה מטעם התובעים*

9. על פי הסכמת הצדדים שקיבלה תוקף של פסק דין חלקי טענת ה"קיפוח" איננה נדרשת להכרעה אלא אך הטענה בדבר פגיעה עקב הצעה אלטרנטיבית עדיפה. ממילא גם אין כל קיפוח – התוספת על פי תמ"א 38 הינה תוספת מטריית קבועה. גם הנתבעים עצמם ביססו את טענותיהם על תוספת קבועה זו; אין בידי הנתבעים כל ראיה לבעלותם בחלל גג הרעפים וגם השמאי קבע כאמור; אין בידי הנתבעים זיקת הנאה לחנייה שהינה זכות שאיננה כוללת זכות חזקה, אין כל ייחוד חניה בתקנון הבית ובכל מקרה אף אם ישנה זכות



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

**תיקים: 5/437/2014**

**מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב - יפו**

אין לה כל שווי. העובדה כי היזמית הינה גם בעלת דירה בבית איננה מקנה זכות לטעון לאפליה בגין הרווח היזמי. טענה בדבר הפרת הסכם התמ"א איננה מהווה הצדק כלשהו לפסיקת פיצוי, גם לא על פי הסכם הפשרה. פיצול דירה בקומת הקרקע אינו כפיצול דירה בקומה שביעית ולא הוכחה אפשרות כלשהי לפיצול כאמור, גם לא בהצעת צליח. חוות דעת המומחה הינה עדות מקצועית וטענות הנתבעים בסיכומיהם בנוגע אליה אינם אלא בגדר השמצות ותו לא.

**דיון והכרעה**

10. צודקים התובעים כי גדר המחלוקת הנתון להכרעתי הוגדר על ידי הצדדים במסגרת הסכם הפשרה וכמתואר במפורט בסעיפים 3 ו-6 לעיל. לפיכך, אתיחס תחילה לסוגיות אלו, לרבות, טענות הנתבעים בנוגע לחוות דעת השמאי.

לאחר מכן, למען שלמות התמונה, אתיחס להלן גם לטענות הנתבעים בדבר "אפליה" ופגיעה בשוויון ונימוקים אחרים אשר לשיטתם מזכים אותם בקבלת פיצוי.

11. עסקינן בפרויקט על פי חוק החיזוק שמטרתו היסודית הינה חיזוקו של הבית מפני רעידות אדמה. הריסת הבית ובנייתו מחדש תוך הרחבת הדירות של בעלי הדירות והוספת דירות חדשות הינם אך בגדר הטבות ותמריצים תכנוניים לבעלי הדירות לשם ביצוע עבודה יסודית שמטרתה חיזוק הבית. בהתאם לעקרונות יסוד אלו יש לבחון את מכלול ביצוע הפרויקט, לרבות, השוויון בין בעלי הדירות בבית בקבלת התמורות, ודאי בנסיבות בהן מדובר בפרויקט הכולל הריסת הבית והקמתו מחדש (ר' בהרחבה תיק 573/11 אוהד קופמן ואח' נ' דב שומרוני (פורסם באתר משרד המשפטים) וערעור על פסק דין זה בעש"א (ת"א) 4166-04-13 דב שומרוני נ' אוהד קופמן ו-14 אח' (פורסם בנבו) וכן רע"א 1002/14 דב שומרוני נ' אוהד קופמן ו-14 אח' (פורסם בנבו)).

ויוזכר, על פי הפסיקה האמורה בידי רוב בעלי הדירות הזכות להחליט לא רק על עצם ביצוע פרויקט החיזוק אלא גם על דרך הביצוע, לרבות, בחירת היזם, קביעת תנאי ההסכם, דרך ההתקשרות וכיוצ"ב. בנסיבות דנן 8 מתוך 9 בעלי דירות בבית הסכימו לביצוע הפרויקט לרבות התנאים הקונקרטיים ופרטי ההתקשרות עם היזם כולל קביעת התמורות שמקבל כל בעל דירה במסגרת הפרויקט. לאור פסק הדין החלקי הרי שכל בעלי הדירות, כולל הנתבעים, נתנו הסכמתם לפרויקט ותנאיו.

על רקע זה עלינו לבחון את ההכרעה הנדרשת בתובענה דנן על פי הסכם הפשרה.

12. לאחר ששקלתי את מכלול טיעוני הצדדים וחוות דעת השמאי, לרבות, תשובותיו לשאלות הנתבעים, אני מוצא כי הנתבעים אינם זכאים לפיצוי בגין ההצעה החלופית או לפיצוי בגין דרישות הנתבעים.

13. מחוות דעת השמאי עולה כי שווי דירת התמורה של הנתבעים על פי הפרויקט המבוצע יעמוד על סך של 3,180,000 ₪ (דירה בקומה 7 חזית מערב צפון בגודל 118 מ"ר) בעוד על



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

תיקים: 5/437/2014

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב - יפו

פי הצעת צליח שווי דירת תמורה יעמוד על סך של 3,000,000 ₪ (דירה בקומה 4 בגודל 118 מ"ר כמפורט בהצעה בנספח 14 לתצהיר קינן). השוואת קומה לדירת התמורה בהצעת צליח (דירה בקומה 7) משווה גם את שווי דירת התמורה (ר' פרק טז לחוות הדעת וסעיף 2.א.3.ב לתשובות לשאלות ההבהרה).

14. לפיכך, על פני הדברים, הצעת צליח היא זו הגורמת לפיחות בשווי זכויות הנתבעים. ויודגש, אין כל אזכור בהצעת צליח ל"שדרוג" קומת דירת התמורה של הנתבעים, גם לא על פי העיקרון הכללי המוזכר בהצעה במפורש בדבר "עליה" של עד שתי קומות בלבד לכל בעל דירה שיחפוץ בכך.

15. קביעת השמאי כאמור מתבססת על הצעת צליח כמפורט בפרק יב' לחוות הדעת, לרבות, לעניין קומת דירת התמורה של הנתבעים ולרבות התייחסות למסמך בכתב יד ללא תאריך בחתימת מר צלאח ולפיו תינתן אפשרות לכל בעלי הדירות לפיצול דירותיהם (בכפוף לאישור העירייה), יקבע גובה תקרה מינימלי ותינתן אופציה לרכישת חניה נוספת במחיר עלות (עמוד 40 לחוות הדעת).

16. לאור סעיף 4 להסכם הפשרה אדגיש כי מעבר לכך השמאי אינו קובע כל תוספת שווי כאמור בגין רכיבי ההצעה הנוגעים לגובה דירה או אפשרות רכישת חניה נוספת במחיר עלות לכל בעל דירה, גם לא עלתה כל טענה בסיכומי הנתבעים בנוגע לזכאות לפיצול כלשהו בגין רכיבים אלו בהצעת צליח או כל טענה כנגד קביעות השמאי בהקשרים אלו.

ממילא גם לא הוכחה כל היתכנות תכנונית או כלכלית לביצוע הפרויקט באופן האמור. גם הצעת צליח בהקשר זה הינה גולמית בלבד, אם וככל שניתנה, ואין לנתוני ההצעה אמורים כל זכר - לא במסגרת ההצעות הרשמיות (נספחים 14 ו-16 לתצהיר קינן) ואף לא בתצהירו של מר אורן צליח שהוגש מטעם הנתבעים.

17. יוצא, אם כן, כי אין כל הבדל מהותי בין הצעת צליח לבין הפרויקט המבוצע, גם אם לוקחים בחשבון את כל אותם אלמנטים "נוספים" בהצעת צליח אשר שימשו יסוד לטענת הנתבעים לקיפוח זכויותיהם.

18. נכון יהיה להאיר כי על פי חוות דעת השמאי חלקם היחסי של הנתבעים בשווי זכויות הבניה הניתנות למימוש על הגג הינו 77,000 ₪ בלבד. זוהי, למעשה, ה"עלות" היחידה של הנתבעים בגין השבחת קניינם בדירת התמורה (בסך של למעלה ממיליון ₪!) (ר' עמוד 46 לחוות הדעת).

19. מחוות הדעת השמאי עולה בבירור גם כי כל "פיחות" בשווי זכויות הנתבעים בדירות התמורה בהשוואה שבין ההצעות השונות עניינו אך בתנאים שונים המוצעים לנתבעים - הגדלת שטח דירת התמורה ל- 141 מ"ר ואפשרות פיצול הדירה ל- 2 או 3 דירות בכפוף לאישור רשויות התכנון - הנתבעים אינם זכאים לקבלת כל פיצוי בגין ה"פיחותים" האמורים.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

תיקים: 5/437/2014

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב - יפו

20. ראשית, אין כל הצדקה להגדלת שטח דירת הנתבעים בהעדפה על פני כל בעלי הדירות האחרים בבית. ויודגש, הצעת מצליח איננה כוללת הגדלת דירות התמורה של מי מבעלי הדירות בבית, לרבות דירת הנתבעים (ר' פירוט דירות תמורה בהצעה בנספח 14 לתצהיר קינן). הגדלת דירת התמורה של הנתבעים בלבד, אם וככל שכך הוסכם עם צליח, מהווה העדפה פסולה ובלתי שוויונית שלהם על פני בעלי הדירות האחרים בבית ובוודאי שאיננה מזכה בקבלת פיצוי כלשהו. ממילא, גם להצעה זו אין כל זכר, לא רק בהצעה ה"רשמית" כאמור, אלא גם בתצהירו של מר צליח.

ויוער, גם כיום בקביעת דירות התמורה ישנה הפליה מסוימת לטובת הנתבעים שעה שהם מקבלים דירה בקומה גבוה יותר מאשר להם זכאים על פי עקרונות החלוקה (ר' לעיל הפרש השווי לדירה בקומה רביעית מול דירה בקומה שביעית וביחס לדירות התמורה אותם מקבלים כל בעלי הדירות האחרים בבית).

21. שנית, באופן דומה גם דרישה לפיצול דירת התמורה של הנתבעים בלבד, בין אם ל- 2 דירות ובין אם ל- 3 דירות, הינה העדפה פסולה של הנתבעים על פני בעלי הדירות האחרים.

מדובר בפעולה אשר לה משמעות כלכלית – על פי חוות דעת השמאי בכך משיאים הנתבעים את שווי דירת התמורה במאות אלפי שקלים, עד כדי 300,000 ₪ (לפיצוי דירת התמורה בקומה שביעית ל- 2 דירות בגודל 59 מ"ר – סעיף 2.3.א.ב להשלמה לחוות הדעת) ועד כדי 750,000 ₪ הפרש בגין פיצול ל- 3 דירות בנות 47 מ"ר (סעיף 1.ב. להשלמה לחוות הדעת).

פיצול דירת התמורה מהווה גם שינוי קנייני משמעותי שאינו נכלל בגדר הוראות חוק החיזוק - אין מדובר בהרחבת דירה (על פי סעיף 4 לחוק החיזוק), אין מדובר בשינוי ברכוש המשותף (על פי סעיף 3 לחוק החיזוק) ולא בניית דירה חדשה (על פי סעיף 5 ו- 5א לחוק החיזוק). לפיכך, דרישה זו איננה מזכה בפיצוי, שכן, אף אם היתה הסכמה של רוב בעלי הדירות לביצוע הפעולה האמורה, לא ניתן היה לאשר אותה במסגרת הוראות חוק החיזוק ללא הסכמה פה אחד של כל בעלי הדירות בבית. הסכמה כאמור איננה מתקיימת בנסיבות דנן.

22. ממילא גם לא הוכחה אפשרות תכנונית לפיצול הדירות, בין אם בקומה שביעית ובין בכל גודל של דירה מופצלת. מטעם הנתבעים לא הוגשה כל ראיה תומכת בהקשר זה, לרבות, אישור כלשהו של מוסדות התכנון או אף חוות דעת הנדסית. גם מחוות דעת השמאי לא עולה כי פיצול הדירות כאמור אפשרי מבחינה תכנונית כפי שמודגש בחוות הדעת "אם וככל שהיה ניתן" (ר' עמוד 46 לחוות הדעת עם ההדגשה במקור).

23. ויודגש, לא הוכחה אפשרות לאשר תכנונית את הפרויקט תוך מתן אפשרות לכל מי מבעלי הדירות אשר ירצה בכך לפצל את דירתו. למעשה, האמור גם אינו מוצע באופן ברור



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

תיקים: 5/437/2014

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב - יפו

ומפורש בהצעת צליח. גם ההצעה "בכתב יד" אליה מתייחס המומחה קובעת כי היא "בכפוף אישור העירייה" (עמוד 40 לחוות הדעת).

24. זאת ועוד. הוכח בפניי כי הצעת צליח הינה הצעה ראשונית בלבד ללא כל סימוכין טכנוני. מתצהירו של מר צליח עולה כי כל שנבדקה על ידו היתה היתכנות למימון בנקאי (סעיף 23-25 לתצהיר). אין כל אזכור, וממילא לא כל טענה, כי בוצעה על ידו בדיקה טכנונית מפורטת כלשהי.

25. הנתבעים גם אינם זכאים לפיצוי כלשהו בגין טענתם בדבר זכויות כלשהן בחלל הגג.

26. הבית דנן רשום בפנקס הבתים המשותפים ורישום קנייני זה מחייב, ודאי כאשר עסקינן בתובענה בפני מפקח על רישום מקרקעין, המחויב לפסוק על פי המצב הרישומי הקיים (ר' רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אוננו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487).

ממסמכי רישום הבית המשותף, המצויים בידיעתי השיפוטית, עולה כי חלל הגג לא הוצמד לאיזה מהדירות בבית ולפיכך, בהתאם להוראות חוק המקרקעין, חלל גג זה מהווה רכוש משותף (ר' הגדרת "דירה" ו- "רכוש משותף" בסעיף 55 לחוק המקרקעין וכן סעיף 55(ג) לעניין הוצאת חלקים מהרכוש המשותף שלא התקיימה בבית דנן).

ויודגש, בתשריט הבית המשותף מופיע אותו "חלל הגג" ואף על פי כן אין הוא מסומן, בכל דרך, כחלק מדירת הנתבעים. חלל הגג אינו מופיע כחלק מדירת הנתבעים גם בחישוב השטחים בתשריט ובמסמכי הרישום. בפרט אמורים הדברים כאשר רישום הבית המשותף דנן מבוסס על תשריט "הועדה לבניה ותכנון ערים רמת גן" וכולל תיעוד של חתך רוחב.

27. טענות הנתבעים כי חלל הגג "שייך" לדירתם בשל קיומה של תקרת רביץ אין בה די כדי להקנות להם זכויות קנייניות מקום בו נרשם בית משותף אשר קבע את גבולותיה הקנייניים הברורים של כל דירה ודירה, כולל תשריט חתך רוחב כאמור.

ויוער, במשך שנים לא ננקט כל הליך על ידי הנתבעים להכרה בזכויותיהם הנטענות בחלל הגג או לתיקון מסמכי רישום הבית המשותף (שנרשם עוד בשנת 1958!). אין הנתבעים זכאים עתה לפיצוי כלשהו בגין השימוש בגג האמור במסגרת הוראות חוק החיזוק, ודאי בהעדר כל ראיה להוכחת טענת בעלות או זכות קניינית כלשהי בחלל גג זה.

28. אף אם הנתבעים עושים שימוש בחלל הגג הרי שאין בשימוש זה, כשלעצמו, להקנות להם זכות קניינית. ויודגש, על פי חוות דעת המומחה אומנם ישנה גישה לחלל הגג מדירת הנתבעים. אולם, ללא מדרגות או סולם קבוע וללא דלת גישה לגג (עמוד 9 לחוות הדעת). לכל היותר בידי הנתבעים זכות שימוש מכלל לאחסון בשטח הגג (גם לאור גובה חלל הגג), שניתן להפסיקה לשם ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית וכפי שידון עוד בהרחבה להלן.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

תיקים: 5/437/2014

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב - יפו

29. זאת ועוד. השמאי גם אינו מוצא כל ערך כלכלי נוסף לזכויות הנטענות של הנתבעים בחלל הגג, על פי המצב הקיים, ודבריו ברורים לחלוטין בהקשר זה - "יודגש כי הואיל ולא קיימת הצמדה של הגג ולא הוצמדו זכויות בנייה נוספות, לכל אחד ואחד מבעלי הזכויות בדירות העליונות תוספת שווי פחות או יותר זהה, בכפוף לחלקם היחסי ברכוש המשותף. תוספת שווי זו אמורה להיות מגולמת בשווי השוק של הדירות העליונות בבית" (ר' בסעיף 4 פרק טז בעמוד 46 לחוות הדעת).

30. הנתבעים גם אינם זכאים לפיצוי כלשהו בגין טענתם לקיומה של זכות קניינית לחניית אופנוע ברחבת הכניסה לבית.

31. ראשית, לא הוכח כי בידי הנתבעים כל זכות קניינית בשטח האמור – אין כל אינדיקציה במסמכי רישום הבית המשותף או פנקסי המקרקעין לקיומה של זכות כלשהי של הנתבעים. שוב, מדובר בבית משותף שנרשם לפני למעלה מ- 50 שנה וללא כל פעולה משפטית מצד הנתבעים לתיקון המצב הרישומי. גם מאז טענת ה"רכישה" חלפו למעלה מ- 25 שנים ללא כל הסדרה קניינית של הזכות הנטענת, בין בתיקון צו הרישום ובין ברישומה של הערה כלשהי בפנקסים.

32. שנית, אין בידי הנתבעים כל אסמכתא הסכמית לזכות הקניין שנטען כי רכשו - לתצהירו של מר קינן לא צורף כל הסכם, הסכמת בעלי דירות, פרוטוקול או החלטת אסיפה כללית, פירוט עבודות, חשבונית, אישור תשלום מיסי מקרקעין או אפילו דיווח על העסקה הנטענת. גם עדותו בהקשר זה (בסעיף 99 לתצהיר) חסרה ביותר - אין כל פירוט לכספים ש"שולמו" במסגרת השיפוץ הנטען, אין כל פירוט לנסיבות הסכמת בעלי הדירות הנטענת ולמהותה של ההסכמה (האם היתה בגדר "מכירת" זכות), אין פירוט לזהות אותם בעלי דירות שהסכימו, אין כל פירוט בנוגע לדיווח מס בגין רכישת זכות במקרקעין כנטען ואפילו לא ראיה מספיקה בנוגע לעבודות התמורה שלכאורה בוצעו. ממילא אין אפילו טענה מפורשת בתצהיר כי מדובר היה בהסכמה של כל בעלי הדירות בבית, היא היחידה אשר יש בה כדי ליצור זכות קניינית ברכוש המשותף.

33. אומנם, הסכמת בעלי הדירות לשימוש ברכוש המשותף והקניית זכויות קנייניות איננה חייבת להינתן בכתב דווקא ואף הסכמה בעל פה בהקשר זה קבילה. הסכמה כאמור יכולה להילמד גם מכללל ומהתנהגות הצדדים לאורך שנים. אולם, בכדי ליתן תוקף קנייני להסכמה הרי שזו צריכה להיות מפורשת ולא ניתן ללמוד עליה במשתמע (ע"א 815/81 כליפא נ' שאול פ"ד לו(3) 78; ע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף (פורסם בנבו); ר' ע"א 9502/06 (מחוזי - י-ם) רונית לומברוזו נ' מיכאל קובנר (פורסם בנבו); ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פד"י לא(3) 210). בנסיבות דנן אין כל ראיה לקיומה של הסכמה מפורשת כנדרש על פי ההלכה, ודאי לא של כל בעלי הדירות בבית במועדים הרלבנטיים.

34. שלישית, אומנם, משעה שניתנה הסכמה ורשות שימוש, אין להתיר לבעל דירה שהסכים להתנער מהסכמתו או לחזור בו ממנה כאשר קיימים של מניעות מטעמי צדק (פרשת כליפא לעיל וכן ע"א 19/81 ביבי נ' הוברט פ"ד לז(2) 497; ע"א 31/70 כהן נ' שמאי



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

תיקים: 5/437/2014

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב - יפו

פד"י כ(2) 388. בהתאם, במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושבהם, בהסתמך על מתן הרישיון, נוצרה צפייה לגיטימית אצל בעל הרישיון כי הרשות ניתנה לצמיתות, אפשר ושיקולי הצדק יביאו להכרה ברשות השימוש כבלתי ניתנת לביטול, אף בהעדר הסכמה מפורשת מצד בעל הקניין (ר': ע"א 32/77 הנ"ל; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם בנבו). שיקולי הצדק בהקשר זה יתבססו, בין היתר, על בחינת כוונת הצדדים בעת יצירת הרישיון, תנאי הרישיון, משך זמן ההחזקה ללא התנגדות והשקעות שהשקיע בעל הרישיון בנכס (היקפו, טיבן והסכמת בעל הזכויות לביצוען) (ר' עמ"ש 14-37005-01 פלוני נ' פלוני (פורסם בנבו) והאזכורים שם). תום הלב של הצדדים מהווה גם הוא רכיב נדרש בבחינת שיקולי הצדק.

בנסיבות דנן לא הוכח כי רשות השימוש שניתנה, ככל שניתנה, הינה בלתי חוזרת - לא הוכח כי שולם תשלום כלשהו בגין זכות החניה או רכישת השטח האמור מבעלי הדירות; לא הוכח כי מדובר בזכות שימוש ייחודית לאורך שנים; לא הוכחו השקעות כלשהן, וממילא אין כאלו, מצד הנתבעים (ר' תיאור השימוש בחוות דעת המומחה ובתצהירי הצדדים, לרבות, התמונות שצורפו).

וידגש, אף אם ניתנה בידי הנתבעים רשות שימוש הרי שקיים במקרה דנן שינוי נסיבות, ואף שינוי קיצוני - ביצוע פרויקט על פי תמ"א 38 תוך הריסתו והקמתו מחדש בהתאם להוראות חוק החיזוק. הצדק טוב מזה להפסקת רשות שימוש מכללל ברכוש המשותף אין! (לבד מפסקי הדין המוזכרים לעיל ר' גם בתיק (מפקח ת"א) 453/14 שמואלי עופר נ' פרידה כהן (פורסם באתר משרד המשפטים) ופסקי דין נוספים המוזכרים שם).

35. רביעית, אין דבר בטענת הנתבעים בדבר קיומה של זכות מסוג זיקת הנאה לחניית האופנוע ברכוש המשותף - סעיף 5 לחוק המקרקעין מגדיר זיקת ההנאה כ"שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמו זכות להחזיק בהם". חניית אופנוע, מעצם טיבה וטבעה, כוללת חזקה בשטח הנדון. למעשה, הנתבעים טוענים לקיומה של זכות חזקה בלעדית ובלתי חוזרת! די בכך כדי להשמיט את הטענה הקניינית של הנתבעים בהקשר זה - לא יכולה להתקיים זכות מסוג "זיקת הנאה" שעצם טיבה הינו חזקה במקרקעין.

36. חמישית, אף אם בידי הנתבעים "רשות שימוש" מבעלי הדירות בבית, בין בהסכמה מפורשת ובין מכללל, הרי שמבחינה שמאית אין כל ערך לזכות זו כפי שמבהיר השמאי במפורש (ר' סעיף 4ב לפרק טז בעמוד 47 לחוות הדעת ובמפורש בסעיף 2ב להשלמה לחוות הדעת).

37. לא מצאתי דבר בטענות הנתבעים כנגד חוות דעת השמאי.

38. ראשית, מדובר בשמאי אשר מונה בהתאם להוראות סעיף 6א לחוק החיזוק. הוראת חוק זו מורה למפקח כי במקרה בו הוא סבור כי נדרשת עמדה שמאית לשם הכרעה בתובענה על



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

תיקים: 5/437/2014

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב - יפו

פי חוק החיזוק עליו להיעזר בשמאות של שמאי על פי חוק פינוי בינוי. השמאי גרש מונה על ידי שר המשפטים כשמאי פינוי בינוי על פי חוק פינוי בינוי (פיצויים), תשס"ו - 2006, על כל המשמעויות הכרוכות בכך - מדובר בשמאי מקצועי בתחום הנדון (ור' פרק פרטי המומחה, השכלתו וניסיונו המקצועי), בפרט בנוגע לפרויקט מכוח תמ"א 38/2, כפי זה הנדון בהליך דנן.

39. שנית, לנתבעים ניתנה רשות לשאול את המומחה שאלות הבהרה בהחלטותיי מיום 08.10.15 ו- 01.11.15 בתיק ב"ב 615/15. דא עקא, הנתבעים בחרו שלא לשאול את המומחה דבר בנוגע לסוגיות השמאות שמועלות על ידם במסגרת הסיכומים, לרבות, טענתם בנוגע ל"הערכה בחסר" של דירתם הקיימת, שווי מ"ר, עסקאות השוואה וכיוצ"ב. לא ניתן לתקוף חוות דעת מקצועית בדרך עקיפה בסיכומים, ללא כל ראיה כדין (בהקשר זה, למשל, ללא היתר 10437 או כל ראיה אחרת בנוגע לשטח דירת הנתבעים) וללא אימות המומחה עם הטענות המקצועיות כנגד קביעותיו השמאיות.

40. שלישית, המומחה "השיב" לכל הסוגיות אותן התבקש לשום במסגרת חוות דעתו. אומנם, חלק מהקביעות ניתנו במסגרת השלמה לחוות דעת. אולם, סופו של יום כולן עמדו בפניו בטרם מתן פסק הדין.

וידוגש, אין ממש בטענת הנתבעים כאילו המומחה לא שם את "שווי חניית האופנוע" - במסגרת השלמה לחוות הדעת התייחס המומחה, שוב, לסוגיה זו במפורש וקבע את עמדתו השמאית בהקשר זה כמפורט לעיל.

41. רביעית, על פני הדברים לא מצאתי כל קביעה שגויה בחוות דעת המומחה - אף אם לשיטת הנתבעים שווי מ"ר מבונה גבוה יותר מאשר זה אותו שם השמאי, הרי שאין בכך להשפיע על עצם ההכרעה הנדרשת בהליך זה - בכל מקרה אין באיזה מטענות הנתבעים בנוגע לשמאות להביא לתוצאה לפיה ביצוע הפרויקט כמבוקש מביא לפיחות כלשהו בזכויות הנתבעים לעומת הצעת צליח. הנתבעים עדיין מרוויחים, ובאופן יחסי עדיין הרווח גדול יותר מאשר בהצעת מצליח. הדברים האמורים נכונים גם בנוגע לטענה בדבר טעות בשומה ביחס מספר החדרים בדירת הנתבעים - הערכת השווי בוצעה על פי גודל היחידה (לפי שטח מדוד) ולא על פי מספר החדרים (ר' סעיף 2 לפרק טו לחוות הדעת).

42. לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי מתקיימת כל אפליה או פגיעה בשוויון אשר מצדיקה קביעת תשלום פיצוי כלשהו.

43. ראשית, הוכח בפניי כי הסכם התמ"א מעניק תנאים זהים לכל בעלי הדירות ללא העדפה של מי מבעלי הדירות. וידוגש, בעלי הדירות מקבלים במסגרת הפרויקט הרחבה זהה לגודל הדירות הקיימות ושדרוג קומה. למעשה, הנתבעים הם אלו אשר "מופלים לטובה" ביחס לבעלי הדירות האחרים שעה שהם מקבלים שדרוג עודף בקומת דירתם (שדרוג לו משמעות כספית כמפורט לעיל).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

תיקים: 5/437/2014

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב - יפו

44. ויודגש, הפרויקט מטיב עם הנתבעים אשר "תמורת" זכויותיהם היחסיות בגג ובזכויות הבניה (ששווין היחסי הוערך על ידי השמאי בסך של 77,000) זוכים להשבחת שווי דירתם בכ- 50% מערכה הנוכחי, כ- 1,095,000 ₪ (ר' פרק טז לחוות הדעת).

45. שנית, ממילא, בעלי הדירות מקבלים הרחבה מקסימלית אפשרית לדירותיהם על פי התמ"א (25 מ"ר לכל דירה) כפי שמאשרים גם עדי הנתבעים.

46. שלישית, השוואת דירות התמורה לחלק הבעלות היחסי של הנתבעים בבית המשותף מלמדת כי גם מבחינה יחסית לא רק שלא נגרע חלקם היחסי בזכויות בהשוואה לבעלי הדירות האחרים בבית אלא שהוא אף משתפר - על פי המצב הקנייני הרישומי לנתבעים 65/510 חלקים ברכוש המשותף (כ- 12.75%) שהינם נגזרת של יחס שטח הרצפות הרישום של הדירות בבית. על פי גודל דירות התמורה (עמוד 35 לחוות הדעת) חלקם של הנתבעים הינו 118/904 (כ- 13.05%).

לפיכך, מבחינה עובדתית אין ממש בטענת הנתבעים כאילו הרחבה בגודל שווה לכל דירות הבית גורמת לפיחות כלשהו בזכויותיהם או לפגיעה בשוויון.

47. רביעית, במסגרת פרויקט על פי חוק החיזוק לעולם לא יכול להתקבל תמורה שוויונית מוחלטת מבחינה כספית בין כל בעלי הדירות. כפי שכבר פסקתי בעבר, "במסגרת פרויקט על פי חוק החיזוק לעולם לא יכול להתקבל תמורה שוויונית מוחלטת מבחינה כספית בין כל בעלי הדירות - כשם שבעלי הדירות בקומות העליונות נהנים יותר מאשר בעלי הדירות בקומות התחתונות מתוספת מעלית בבית במסגרת הפרויקט, הרי שבעלי הדירות העליונות הם גם אלו אשר "סופגים" את עיקר המטרדים בגין תוספת היחידות בקומת הגג ואת השינוי המשמעותי ביותר למיקום דירתם בבית (מקומת גג לקומת ביניים בשל תוספת דירות הגג). כך גם אמורים הדברים לגבי מיקומי חניות, מיקומי חיזוקים ו"הנאות" או "הפרעות" אחרות מפעולות המבוצעות במסגרת פרויקט תמ"א 38. מטבעו של בית משותף הכולל דירות בקומות שונות בעלות אבחנות אינהרנטיות (כיווני אוויר, מיקום, קומה וכיוצ"ב), בהכרח ישנם הבדלים בערכים כספיים מוחלטים בין הדירות והשלכות שמאיות רלבנטיות שאינן ניתנות לביטול או ניטרול. בהתאם גם את ה"שוויון" הכלכלי ניתן לבחון, לכל היותר, בין דירות באותה קומה" (ר' בהרחבה בתיק (מפקח ת"א) 95/14 שמש שואל ואח' נגד פרנקו דינה ואח' (פורסם באתר משרד המשפטים)). הדברים נכתבו בנוגע לפרויקט על פי תמ"א 38/1. אולם, הם נכונים בהתאמה גם לפרויקט על פי תמ"א 38/2 - אף שניתן במידה מסוימת לאזן בזכויות בעלי הדירות לאור הריסת הבית ובנייתו מחדש, הרי שסופו של יום גם בפרויקט זה הבית החדש אינו זהה לזה שנהרס, ובהתאם גם זכויות הצדדים משתנות.

בהתאם לעקרונות האמורים הרי לא עלה בידי הנתבעים להראות כי מי מבעלי הדירות האחרים מקבל תמורה עודפת אשר פורצת את מסגרת "שוויון" הנדרשת לאישור פרויקט על פי חוק החיזוק (אף אם ההרחבה המקסימלית הניתנת למי מבעלי הדירות על פי התמ"א הינה באופן יחסי גדולה יותר מאשר חלקו הנוכחי). ההפך הוא הנכון - הנתבעים הם אלו אשר מבקשים לקבל לעצמם תמורה נוספת כאמור.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

**תיקים: 5/437/2014**

**מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב - יפו**

48. זאת ועוד. בהתאם להסכם הפרשה שבין הצדדים חתמו הנתבעים על מסמכי הפרויקט ואישרו את ביצועו תוך הותרה לקביעתו של שיעור התשלום המגיע בלבד. בהסכמתם כאמור אישרו, למעשה, גם הנתבעים את "השוויון" הנדרש על פי חוק החיזוק (כפוף לקביעת שיעור הפיצוי).

49. כפי שכבר נפסק בפרשת שומרוני, על כל ערכאותיה כמפורט לעיל, רוב בעלי הדירות בבית זכאי להחליט לא רק על עצם ביצוע פרויקט תמ"א אלא גם דרך ההתקשרות לביצוע הפרויקט. יתכן וישנן דרכים עדיפות לבעלי הדירות לביצוע הפרויקט, ודאי מבחינה כלכלית. יתכן וישנן גם הצעות אלטרנטיביות (דוגמת זו שמעלה מר צליח בתצהירו וזאת מבלי להיכנס כלל לבחינת היתכנות כלכלית ותכנונית להצעה זו שמוטלת בספק בהעדר כל קונקרטיים ובדיקה מקיפה, אף לא מצדו של מר צליח כאמור). אולם, הוכח בבירור כי אין התכנות משפטית לביצוע חלופה אחרת כלשהי לפרויקט בהעדר הסכמה על פי הרוב נדרש של בעלי דירות בחוק החיזוק למתווה החלופי המוצע על ידי הנתבעים. יש גם לזכור כי מתווה זה, לפיו הנתבעים ישתתפו ביזמות בגין חלקם היחסי, מעבר לכך ש"מעדיף" את הנתבעים על פני בעלי דירות אחרים (שהרי אין התכנות להשתתפות ביזמות לכל בעלי הדירות), כופה, למעשה, את רצון המיעוט על החלטת רוב בעלי הדירות בנוגע למתווה לביצוע הפרויקט.

50. הדברים נכונים גם בנוגע לטענת הנתבעים בדבר היות היזם אחד מבעלי הדירות בבית – זכותם של רוב בעלי הדירות הינה גם לבחור את היזם עימו הם מתקשרים לביצוע הפרויקט. לא הוכח, ולמעשה גם אין כל טענה, כי היזם "מקבל" זכויות עודפות כבעל דירה, להבדיל מהתמורות אותן הוא מקבל כיוזם. ויודגש, כל טענות הנתבעים בדבר רכישת דירת המתנגד על ידי היזם הינן בגדר השערות בלבד וללא כל בסיס, ודאי כאשר הנתבעים בחרו שלא להביא לעדות בהליך את ה"קול"יך.

אין ממש גם בטענת הנתבעים לזכאותם לקבלת פיצוי בגין "מטרים" נוספים שהשיגו לבעלי הדירות – ראשית, פיצוי בהקשר זה לא נותר להכרעתי בהתאם להסכמת הצדדים. שנית, מדובר בהתנהלות במסגרת מו"מ למימוש פרויקט תמ"א, כאחד מבעלי הדירות בבית. אין בעל דירה בבית (שלא נבחר כיוזם) זכאי ל"עמלה" כלשהי בגין התקשרות בפרויקט תמ"א בבית, גם לא בנוגע לפעולה אשר מטרתה "מיצוי זכויות".

ויוזכר, מדובר בפרויקט תמ"א בבית משותף ולא בעסקה כלכלית גרידא בין שותפים במקרקעין. השוואת זכויות בעלי הדירות נעשית האחד מול השני ולא ביחס של בעלי הדירות מול היזם (ר' בפרשת שומרוני לעיל וכן בפרשת פרידה כהן המוזכרת לעיל).

51. טענה בדבר הפרה של הסכם התמ"א איננה מהווה פגיעה בשוויון או שיקול המצדיק פסיקת פיצוי כלשהו לנתבעים – בכל הפרה, ככל שישנה, ואינני נדרש כאן לבחינה זו, יש ל"טפל" בהתאם להוראות הדין ובפני הערכאות המוסמכות. אין בכך להשפיע בדבר בנוגע לשיעור הפיצוי המגיע, אם מגיע, בגין הפרויקט, ודאי לאור הסכמת הצדדים ופסק הדין החלקי.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

**תיקים: 5/437/2014**

**מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב - יפו**

**סיכום**

52. לאור כל האמור לעיל הרי שאין הנתבעים זכאים לקבלת פיצוי בגין הפרויקט, לא בהתאם לרכיבים אשר הסכימו הצדדים להותיר להכרעתי על פי פסק הדין החלקי ואף לא בהתאם להוראות סעיפים 5א או 6 לחוק החיזוק.

53. בחינת תום לב הצדדים בנסיבות דנן מגלה כי לא ניתן לייחס למי מבעלי הדירות חוסר תום לב.

מחד, התובעים מבקשים לממש פרויקט תמ"א על פי החלטת רוב בעלי הדירות שהתקבלה כדין. מדובר בפרויקט שוויוני שבכל מקרה יש בו להשביח את זכויות בעלי הדירות.

מאידך, הנתבעים ביקשו למצות את זכויותיהם במסגרת הפרויקט, לרבות, ביחס לזכויות שחשבו כי מצויות בידם ומצדיקה קבלת פיצוי. פעולות הנתבעים גם הביאו להשאת התמורה המתקבלת בידי בעלי הדירות במסגרת ההסכם.

54. לבד מהאמור יש גם לשקול את העובדה כי בסופו של יום הנתבעים התקשרו בהסכם התמ"א במסגרת ההסכם שקיבל תוקף של פסק דין חלקי ואפשרו קידומו ומימושו של הפרויקט במקביל להמשך ההליכים נושא פסק דין זה.

55. לאור האמור, ובהתחשב בכך שהצדדים צריכים עוד לשתף פעולה, האחד עם השני ומול היזם (בכובעו כיזם), הרי שנכון יהיה לקבוע כי בנסיבות דנן, אף שדרישת הנתבעים לקבלת פיצוי נדחתה, לא יעשה צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ו אדר א תשע"ו, 06 מרץ 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן  
מפקח בכיר על רישום מקרקעין